

1501681-84.2019.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Renata Marques de Jesus

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (TJSP, RT 614/275);

"Os policiais não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

1ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato - SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501681-84.2019.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501681-84.2019.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WASHINGTON DE LIMA FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Marques de Jesus

Vistos.

WASHINGTON DE LIMA FERREIRA, qualificado, foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 169, inciso II, e 171, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque em data incerta anterior ao dia 16 de julho de 2019, nesta cidade e Comarca de Francisco Morato, achou um cartão BOM em nome de um idoso e apropriou-se do documento, deixando de restituí-lo ao dono ou de entrega-lo à autoridade competente. Consta, ainda, que na manhã de 16 de julho de 2019, por volta das 10 horas, no interior do coletivo da empresa Auto Ônibus Moratense, que transitava pelo bairro Jardim Rosa, nesta cidade, na posse de documento, obteve para si vantagem ilícita, consistente em uma passagem de ônibus gratuita, induzindo a erro outrem, mediante o meio fraudulento (fls. 2/4).

Preso em flagrante delito (fls. 5), foi concedido o benefício da liberdade provisória (fls. 35/36).

Foi extinta a punibilidade do réu em relação ao crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, na forma do artigo 107, inciso V, do mesmo diploma legal, conforme decisão de fls. 92/93, prosseguindo o feito em relação ao crime previsto no artigo 169, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida (fls. 92/93) e, citado (fls. 132), o réu apresentou defesa prévia (fls. 136/138).

Em sede de instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 168/169). O réu foi declarado revel, uma vez que não localizado no endereço informado (fls. 131/132 e 172), não atendeu às ligações feitas e não ingressou na audiência virtual, cujo link foi encaminhado ao endereço eletrônico de fls. 132. Mídia arquivada.

Em memoriais requereu o Ministério Público a absolvição do acusado em relação ao crime previsto no artigo 169, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal (Fls. 187/190). A Defesa, no mesmo sentido, pugnou pela absolvição do réu (fls. 191/193).

É o relato.
Fundamento e decido.

Preliminarmente, tem-se dos autos que quando do oferecimento da denúncia inviável era o prosseguimento da ação penal junto ao Juizado Especial Criminal em razão da somatória das penas.

Todavia, sendo posteriormente extinta a punibilidade pelo crime previsto no artigo 171, do Código Penal (fls. 92/93), remanesceu aquele previsto no artigo 169, inciso II, do mesmo diploma legal, que contempla uma infração de menor potencial ofensivo, pois o máximo de pena privativa de liberdade cominada em abstrato é compatível com a transação penal e com o rito sumaríssimo, nos moldes da Lei nº 9.099/1995.

Tratando-se de réu reincidente, justificou o Ministério Público a impossibilidade do oferecimento da proposta de acordo de não persecução penal (fls. 1) e, pela mesma razão, não comporta o oferecimento do sursis processual, na forma do artigo 89, da Lei nº 9.099/95.

Este juízo, no âmbito de sua competência, praticou atos decisórios nestes autos, sendo extinto o concurso de crimes. Considerando que se encontra em estágio avançado, com instrução processual encerrada, contraproducente a remessa ao JECRIM a esta altura para prosseguimento do feito em relação ao delito residual (artigo 169, inciso II, do Código Penal).

Considerando, também, que para o STF não há óbice ao julgamento, pela Justiça Comum, de crimes de competência dos Juizados Especiais quando praticados em concurso com delitos mais graves, sem violar o princípio do Juiz natural (ADI 5264, j. 04/12/2020), bem como atenta ao princípio da economia processual e, mediante a garantia de todos os direitos do réu, que foi processado na forma da lei e com atenção aos direitos fundamentais, declaro a competência para a continuidade do processamento do feito.

Superada tais questões que, embora não ventiladas pelas partes, de rigor o esclarecimento por este juízo, a ação penal é procedente.

Em linha tênue, equivocava-se o Ministério Público em suas alegações finais de fls. 187/190 quando assevera que:

"Ocorre que, conforme apurado em investigação própria, WASHINGTON foi autor do

crime de roubo praticado contra Elói, sendo a posse do crachá exaurimento da conduta praticada anteriormente. Com efeito, o réu subtraiu o documento e não apenas deixou de restituir o objeto ao dono depois de encontrá-lo por força do acaso. Com isso, tampouco remanesce o crime do artigo 169, inciso II, do Código Penal, devendo o acusado responder pelo crime de roubo, o que será feito em autos próprios." (fls. 189)

Em igual equívoco incorre a Defesa (fls. 191/193).

De fato, a posse do crachá funcional pertencente à vítima Elói, bem como seus antecedentes de obtenção, é objeto de investigação própria nos autos do Inquérito Policial nº 1501143-77.2019.8.26.0197.

O que se tem nestes autos, todavia, é situação diversa, qual seja, a utilização do cartão BOM pertencente ao idoso Jenilson Marculino da Silva, regularmente apreendido às fls. 6. Foi a utilização deste cartão ("cartão BOM pertencente ao idoso Jenilson"), ao passar pela catraca do coletivo, que levantou suspeita da funcionária cobradora, desencadeando todos os fatos narrados na presente ação penal.

Neste quadro, bem delineada a denúncia de fls. 2/4, que limita a acusação ao cartão BOM pertencente a Jenilson, descrevendo os fatos com extrema clareza.

De forma simples, é possível vislumbrar que, na ocasião dos fatos, dois quadros distintos ocorreram (i) posse e utilização do cartão BOM pertencente à vítima Jenilson e (ii) posse do crachá funcional pertencente a Elói, o qual foi, supostamente, vítima de crime de roubo anterior e figura nestes autos na posição de testemunha.

Com se vê, o que se persegue nesta ação penal é a primeira situação narrada (i), isto é, a apropriação de coisa achada relativa, tão somente, ao cartão BOM pertencente à vítima Jenilson Marculino da Silva.

Neste diapasão, a materialidade do delito previsto no artigo 169, inciso II, do Código Penal, vem comprovada de acordo com o auto de exibição e apreensão de fls. 6, boletim de ocorrência de fls. 22/23, laudo pericial do cartão "BOM" (fls. 57) e demais elementos colhidos durante as fases investigatória e judicial.

Tiago Franca Ricardo, policial militar que atendeu a ocorrência, narrou em solo policial que na data dos fatos encontrava-se à paisana no terminal de ônibus no local dos fatos, ocasião na qual foi solicitado pela cobradora da empresa Auto Ônibus Moratense alegando que um indivíduo havia passado pela catraca do coletivo apresentando um cartão de uso de deficiente, beneficiando-se da passagem e, junto com o cartão, estava outro, pertencente a um cobrador da empresa (Sr. Elói do Nascimento), reconhecendo a cobradora não se tratar da mesma pessoa. Abordou o investigado ao desembarcar do coletivo e, então, deu voz de prisão em flagrante delito, conduzindo-o à Delegacia de Polícia (fls. 9).

E Elói do Nascimento, cobrador de ônibus da empresa Moratense, também ouvido somente na fase inquisitorial, contou que aos 09 de maio de 2019, enquanto estava desempenhando suas atividades profissionais, foi abordado por um indivíduo armado que subtraiu o dinheiro do caixa e seu crachá. Na data dos fatos narrados na denúncia da presente ação penal informou que foi comunicado pelo fiscal Danilo que foi preso um indivíduo com seu crachá e, por isso, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, reconhecendo o réu como autor do roubo do qual foi vítima em momento pretérito (fls. 10).

A testemunha Danilo Cezar Ferreira da Silva declarou que foi comunicado por mensagem pela cobradora Sthefany que um indivíduo havia passado pela catraca do referido coletivo apresentando um cartão de uso de deficiente, conhecido por "BOM",

beneficiando-se da passagem e, que junto com o cartão de deficiente do idoso estava um outro cartão, que se tratava de um crachá de um cobrador da empresa. No referido ônibus, na companhia do Ricardo, policial militar, abordou tal indivíduo encontrando em seu poder tais crachás. Um deles, o de Elói, tratava-se de produto de roubo e o outro o crachá de passe especial não era o titular, tratando-se de documento em nome de outra pessoa (fls. 11). Em audiência relatou que a cobradora o chamou e com o réu foi encontrado o cartão e o crachá de um funcionário. O cartão não era do réu, o qual não conhecia antes (fls. 168).

Por fim, a testemunha Stefany de Jesus Silva, cobradora da empresa Moratense, disse que estava trabalhando no interior de um coletivo quando um indivíduo passou pela catraca apresentando um cartão de uso de deficiente, conhecido por "BOM", beneficiando-se da passagem. Junto com o cartão de deficiente do idoso estava um outro cartão, visualizado pertencer a um cobrador da empresa, Sr. Elói do Nascimento, reconhecendo, de imediato, não se tratar da mesma pessoa, momento em que acionou o fiscal. Este estava na companhia do Policial Militar Rodrigo e ambos compareceram no ônibus indicado, abordando o indivíduo (fls. 12). Em juízo, mantendo sua versão, contou ser cobradora de ônibus. O acusado passou o cartão de deficiente com acompanhante. Nesse momento viu um crachá em nome de outro cobrador, Elói. Liberou a catraca e assim que um fiscal entrou perguntou se o Elói tinha perdido o crachá. Ele informou que havia sido roubado. Avisou que uma pessoa estava no coletivo com o crachá e passou a descrição das vestimentas. O réu desceu no terminal e foi abordado por um policial. Ele disse que tinha achado o crachá. O cartão BOM tinha uma foto pequena. Não conferiu a identidade, mas depois soube que o cartão não era dele, nem de parente (fls. 169).

Na única oportunidade em que ouvido, o réu contou que estava em poder de um crachá, que fora emprestado por seu amigo para que pudesse usar o ônibus, e passou pela catraca da Empresa Moratense, sendo abordado alguns instantes pelo policial militar e conduzido à Delegacia. Em relação ao crachá da pessoa de Elói, aduziu que achou na via pública e posteriormente iria levá-lo na empresa (fls. 17).

Inicialmente, cumpre salientar que a lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos. Aliás, nem teria sentido conferir-lhes a lei determinada tarefa para depois, quando viessem prestar contas de sua atuação, negar-lhes valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não dizem a verdade:

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte” (STJ, Sexta Turma, AgRg no Ag 1158921/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julg. 17/05/2011, DJe 01/06/2011);

“O depoimento de policial obedece os mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (TJSP, RT 752/586);

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo sob garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC nº 74.608-0, Rel. Min. Celso de

Mello, j. 18/02/97, DOU de 11/04/97, p. 189);

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário é de idoneidade destas testemunhas, ainda mais quando os seus depoimentos são seguros precisos e uniformes desde a sede inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (TJSP, RT 614/275);

“Os policiais não são proibidos de prestar depoimento nos processos de cuja fase policial tenham participado, seja efetuando a prisão do agente, seja apreendendo o objeto do crime. De outro lado, a declaração de inidoneidade é específica e não genérica, não podendo abranger toda uma categoria de pessoas, devendo ser alegada e demonstrada em cada caso” (TJMG, RT 604/407).

Ainda, não restou comprovado dos autos que as testemunhas tinham motivos para acusar o réu leviana e gratuitamente.

A partir do contexto probatório extrai-se que as testemunhas prestaram depoimentos coesos e convergentes, reafirmando as declarações prestadas na fase policial, tornando seguro um decreto condenatório.

E, não demonstrou a Defesa eventual motivo que as testemunhas teriam para mentir em juízo deixando, assim de se desincumbir de seu ônus (artigo 156, do Código de Processo Penal), destacando que eventuais e pequenas contradições entre os depoimentos, sequer existentes na hipótese, não são capazes de infirmar o vasto caderno probatório constante dos autos. Nesse sentido:

“PROVA - Pequenas divergências entre os relatos das testemunhas - Irrelevância - Validade. As pequenas contradições na prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do fato” (TACrimSP - Ap. nº 583.153/2 - 7ª Câ. - Rel. José Habice - J. 05.04.90 - RJDTACRIM 6/78).

O réu está sendo processado por, em síntese, ter se apropriado de coisa achada (artigo 169, II, do Código Penal) que, segundo as lições de Victor Eduardo Rios Gonçalves (2019), “o objeto material desse crime é a coisa perdida, assim entendida aquela que se extraviou de seu proprietário ou possuidor em local público (ruas, avenidas, praças) ou aberto ao público (ônibus, metrô, supermercados, casas de espetáculos etc.), pois apenas nesses casos o objeto encontra-se fora da esfera de vigilância do dono” (Direito penal esquematizado: parte especial. - 9. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

E, em relação ao cartão BOM de Jenilson Marculino da Silva, em que pese a alegação do acusado ter obtido de um amigo, sequer identificado, não há provas nos autos a amparar tal versão, tendo-se, em verdade, a informação de que o referido bem foi extraviado e, então, utilizado pelo réu, indevidamente, para obtenção de vantagem.

Friso, novamente, que na data dos fatos não houve a utilização do crachá do funcionário Elói, destacando, vez mais, que foi extinta a punibilidade do réu em relação ao crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, na forma do artigo 107, inciso V, do mesmo diploma legal (fls. 92/93).

Tem-se do Boletim de Ocorrência de fls. 22/23 que o cartão BOM pertencente a Jenilson foi extraviado e não abandonado por seu proprietário. Caso assim fosse, o fato seria inequivocadamente atípico, porque, nas lições de Cleber Masson (Direito

Penal, vl. 2, 11ª Ed., p. 547), quando o sujeito se apropria de coisa abandonada (res derelicta) não há patrimônio merecedor de proteção pelo Direito Penal.

Ainda nas lições do autor supracitado, o núcleo do tipo penal em tela é "apropriar-se", relevando ser indispensável a intenção do agente de ter a coisa para si, com o fim de assenhoreamento definitivo – animus rem sibi habendi. Dos autos, ao utilizar o cartão como se seu fosse, para auferir vantagem, claro está que o réu agiu como dono da coisa.

Há de se observar que o crime é categorizado como "crime a prazo", isto é, somente se consuma depois de transcorrido o prazo de 15 dias legalmente previsto. Nas lições de Cleber Masson (Direito Penal, vl. 2, 11ª Ed., p. 547):

"Destarte, quem encontra uma coisa perdida em local público ou de uso público, e conhece seu dono, tem o dever legal de restituí-la integral e imediatamente. Se, entretanto, a restituição da coisa alheia móvel não for possível (exemplo: o titular do bem reside em local perigoso e de difícil acesso) ou não se souber quem é o seu proprietário, aquele que a encontrou tem o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar sua entrega à autoridade competente, que pode ser policial ou judicial, nos termos do art. 1.170, caput, do Código de Processo Civil. Nessa última hipótese, em que o sujeito não conhece o titular do bem ou não tem condições de restituí-lo imediatamente, trata-se de crime de conduta mista, pois se visualizam duas etapas distintas, uma comissiva e outra omissiva, a saber: comissiva: o agente se apodera de coisa perdida que encontrou em local público ou de uso público, em relação à qual não conhece seu titular ou não possui condições para restituí-la; e omissiva: decorrido o prazo de 15 dias, não a entrega à autoridade pública (policial ou judicial)."

Em arremate, foram reunidas provas suficientes de que o réu, com vontade livre e consciente, apropriou-se de coisa alheia consistente em cartão BOM de Jenilson, deixando de restituí-la ao legítimo proprietário ou de entregá-la à autoridade competente no prazo legal, eis que consta do Boletim de Ocorrência (fls. 22/23) que a perda da coisa deu-se aos 28/12/2018, sendo o réu capturado em posse, em razão do uso da coisa, aos 16/07/2019, portanto, superando o prazo estabelecido no tipo penal em comento.

Vale citar, por fim, que a aplicação do princípio da insignificância deve ser reservada para casos excepcionais, onde, além da ínfima lesão ao bem jurídico tutelado, deve ser analisado o grau de reprovação da conduta e os antecedentes do acusado, conforme os vetores estabelecidos pelo C. Supremo Tribunal Federal:

(...) O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado,

cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. (STF, HC 84412, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00029 EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963) GRIFAMOS

Inferre-se dos autos que o acusado é pessoa dedicada às atividades criminosas, figurando como investigado nos inquéritos policiais nº 494/2019 (art. 140, 147, 163 e 329, CP - autos nº 1502454-38.2019) e nº 493/2019 (art. 171 e 307, CP - autos nº 1501681-84.2019), conforme certidão de fls. 105, tendo sido condenado por crimes contra o patrimônio, conforme certidão de fls. 105/106, configurando, assim, a reincidência.

Desta feita, impossível a aplicação do aludido princípio como causa de exclusão da tipicidade:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Absolvição. PROVA DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Valor do bem. Habitualidade criminosa. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A materialidade e autoria estão devidamente comprovadas nos autos, haja vista o auto de apreensão, além dos depoimentos e declarações da vítima, dando conta de que o agente foi o autor da subtração. 2. O artigo 169, inciso II do CP exige a figura da res desperdita e a verificação do animus rem sibi habende, o que não se verifica nos autos, diante da informação de que o recorrente abriu a bolsa da vítima e subtraiu o aparelho celular que se encontrava no interior, evadindo-se do local em seguida. 3. A aplicação do princípio da insignificância é excepcional, devendo ser levado em consideração, ainda, o grau de reprovabilidade da conduta, periculosidade social da ação e a lesão sofrida pelo ofendido. 4. Considerando as informações de que o apelante possui condenação por delito contra o patrimônio e que a res furtiva possui valor considerável, tem-se por inviável a incidência do princípio da insignificância. Recurso não provido." (TJES, Classe: Apelação, 004140011539, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Data da Publicação no Diário: 20/11/2017)

Neste diapasão, considero que os elementos de convicção carregados aos autos são suficientes para atribuir ao acusado a responsabilidade criminal pela prática do delito, sendo a condenação medida que se impõe, razão pela qual passo a dosar a pena.

De início, destaco que embora o artigo 169, inciso II, do Código Penal, comine pena privativa de liberdade ou, alternativamente, multa, dada a necessidade de prevenção e repressão do crime em tela, tenho que inconveniente a substituição por pena de multa, preferindo a pena de detenção à esta.

Passo a aplicar, portanto, a pena privativa de liberdade e, na primeira fase, diante a existência de maus antecedentes (fls. 31/32, 96/98 - autos nº 1502454-38.2019 e nº 1501681-84.2019), conforme certidão de fls. 105, exaspero a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na fase intermediária da dosimetria tem-se dos autos que, ao tempo da ação (fls. 2/4), o réu possuía condenação transitada em julgado (fls. 31/32 e 96/98 - autos nº 77/2016, em execução sob nº 2038-46.2018), conforme certidão de fls. 105/106, configurando, assim, a agravante da reincidência, justificando a majoração na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Destaco que as versões apresentadas pelo réu não configuram confissão espontânea, porque não assumiu as elementares do tipo penal.

Assim, ausentes demais agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva a reprimenda estabelecida.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto. O acusado é reincidente, lembrando que a generalidade do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, não basta para a aplicação do regime aberto a todos os condenados a pena de prisão inferior a quatro anos. Para garantir-se o princípio constitucional da individualização devem ser observadas sempre as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que são desfavoráveis. Aliás, é isso que dispõe o § 3º, do mencionado artigo 33.

Frente ao imperativo de se examinar particularmente cada caso para se fazer um juízo claro de necessidade e suficiência da reprimenda, não apenas com relação à quantidade dela, mas também quanto ao regime, dentre os previstos em lei, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade sob regime semiaberto.

Sendo o réu reincidente em crime doloso, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, II, do Código Penal) e, pelo mesmo fundamento, inviável a concessão de sursis pena, por expressa disposição legal (art. 77, I, do Código Penal):

"(...) A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, exige, conforme o art. 44 do Código Penal, a somatória de requisitos objetivos e subjetivos. No caso em julgamento, a paciente não apresenta bons antecedentes, o que inviabiliza a substituição e, consequentemente, a concessão do habeas corpus (...)" (STJ, 1ª Turma, HC nº 84075/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06/04/04, DJ 06/08/04)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu WASHINGTON DE LIMA FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 169, inciso II, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03, condenado, o réu arcará com as custas processuais:

"o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei 1.060/50. Precedentes. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação" (REsp. 400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/ 2003,). No mesmo sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 14/09/98. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0008903-30.2009.8.26.0189, Relator Des. Euvaldo Chaib)

Estando solto, poderá o réu apelar em liberdade, não havendo, ainda, razões para que seja decretada a sua prisão cautelar. Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado nos autos, nos termos da tabela do convênio DPE/OAB (fls. 133).

Por fim, em relação aos bens apreendidos às fls. 6, determino a devolução ao legítimo proprietário e, em caso de desinteresse, autorizo a destruição. Oficie-se

a md. Autoridade Policial para a adoção das providências necessárias.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Francisco Morato, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA